Tübingen, 16.10.2026

Matr.-Nr.

7. Semester

Übung im Zivilrecht

für Fortgeschrittene

bei Prof. Dr. Stefan Thomas

Ferienhausarbeit

Wintersemester 2026/27

Inhaltsverzeichnis

Literaturverzeichnis....6
Sachverhalt....7
Gutachten....1
A. Frage 1: Provisionsanspruch der A gegen K aus § 652 I 1 BGB....1
I. Entstehung des Anspruchs....1
1. Zustandekommen eines wirksamen Maklervertrags....1
a) Einigung durch Angebot und Annahme, §§ 145 ff. BGB....1
aa) Angebot durch das Exposé, § 145 BGB....1
bb) Vertragsschluss in den Geschäftsräumen der A....1
b) Einbeziehung und Wirksamkeit der Provisionsklausel....1
aa) Anwendbarkeit der §§ 305 ff. BGB, § 310 III BGB....2
bb) Provisionsklausel als AGB, § 305 I 1 BGB....2
cc) Einbeziehung in den Vertrag, § 305 II BGB....2
dd) Keine vorrangige Individualabrede, § 305b BGB....2
ee) Keine überraschende Klausel, § 305c I BGB....2
ff) Inhalts- und Transparenzkontrolle, § 307 BGB....3
gg) Zwischenergebnis zur Provisionsklausel....3
c) Anwendbarkeit der Sondervorschriften der §§ 656a ff. BGB....3
aa) Verbrauchereigenschaft der K, § 656b BGB....3
bb) Einordnung als Einfamilienhaus i.S.d. §§ 656a ff. BGB....4
cc) Zwischenergebnis zur Anwendbarkeit....4
d) Einhaltung der Vorgaben der §§ 656a ff. BGB....4
aa) Wahrung der Textform, § 656a BGB....5
bb) Halbteilungsgrundsatz bei Doppeltätigkeit, § 656c I 1 BGB....5
cc) Zwischenergebnis zu den §§ 656a ff....5
e) Widerruf des Maklervertrags, §§ 355 I, 312g I BGB....5
f) Kündigung des Maklervertrags....6
g) Nichtigkeit infolge Anfechtung, § 142 I BGB....6
aa) Erklärung der Anfechtung, § 143 I, II BGB....6
bb) Vorliegen eines Anfechtungsgrundes, § 119 I BGB....6
cc) Rechtsfolgenirrtum als Inhaltsirrtum, § 119 I Alt. 1 BGB....7
dd) Zwischenergebnis zur Anfechtung....7
2. Nachweis der Gelegenheit zum Vertragsschluss, § 652 I 1 BGB....7

3. Wirksamer Abschluss des Hauptvertrags....8
4. Ursächlichkeit der Maklertätigkeit....8
5. Höhe der Provision....9
6. Zwischenergebnis zur Entstehung....9
II. Durchsetzbarkeit des Provisionsanspruchs....9
1. Auskunftsanspruch der K aus § 242 BGB....9
2. Einsichtsanspruch der K aus § 810 Fall 2 BGB....9
a) Maklervertrag als Urkunde....9
b) Bezug der Urkunde zu einem Rechtsverhältnis der K....10
c) Rechtliches Interesse an der Einsichtnahme....10
d) Besitz der Urkunde durch A....10
e) Zwischenergebnis zu § 810 BGB....11
3. Einrede des Zurückbehaltungsrechts, § 273 I BGB....11
a) Gegenseitigkeit der Ansprüche....11
b) Konnexität der Ansprüche....11
c) Fälligkeit und Durchsetzbarkeit des Gegenanspruchs....11
d) Rechtsfolge des Zurückbehaltungsrechts, § 274 I BGB....11
e) Zwischenergebnis zu § 273 BGB....12
III. Ergebnis zu Frage 1....12
B. Frage 2: Räumungs- und Herausgabeansprüche der K gegen T....12
I. Räumungsanspruch der K gegen T aus § 546 I BGB....12
1. Eintritt der K in das Mietverhältnis, § 566 I BGB....12
2. Wirksame Beendigung des Mietverhältnisses....13
a) Außerordentliche fristlose Kündigung, § 543 I, II 1 Nr. 3 BGB....13
aa) Mietrückstand und Minderungsrecht, §§ 536, 536b BGB....13
bb) Verzug mit zwei Monatsmieten, § 543 II 1 Nr. 3 lit. b BGB....14
cc) Keine Abmahnung erforderlich, § 543 III 2 Nr. 3 BGB....14
dd) Unwirksamkeit durch Schonfristzahlung, § 569 III Nr. 2 BGB....15
b) Hilfsweise ausgesprochene ordentliche Kündigung, § 573 BGB....15
aa) Zulässigkeit und Eintritt der Bedingung....15
bb) Berechtigtes Interesse der K, § 573 I 1, II Nr. 1 BGB....15
cc) Schonfristzahlung und ordentliche Kündigung....16
dd) Einhaltung der Kündigungsfrist, § 573c I BGB....16
ee) Form und Begründung, §§ 568 I, 573 III BGB....16

ff) Sozialwiderspruch der T, §§ 574 ff. BGB....17
gg) Zwischenergebnis zur ordentlichen Kündigung....17
3. Ergebnis zum Räumungsanspruch....17
II. Herausgabeanspruch der K gegen T aus § 985 BGB....17
1. Eigentum der K am Grundstück....17
2. Besitz der T an der Wohnung....18
3. Fehlendes Besitzrecht der T, § 986 I BGB....18
4. Ergebnis zu § 985 BGB....18
C. Frage 3: Kautionsrückzahlungsanspruch der T gegen K aus der Kautionsabrede i.V.m. § 566a S. 1 BGB....18
I. Entstehung des Rückzahlungsanspruchs....18
1. Wirksame Kautionsabrede zwischen V und T, § 551 BGB....18
2. Übergang der Rückgewährpflicht auf K, § 566a S. 1 BGB....18
3. Beendigung des Mietverhältnisses und Rückgabe der Wohnung....18
4. Zwischenergebnis zum Rückzahlungsanspruch....19
II. Erlöschen durch Aufrechnung, § 389 BGB....19
1. Gegenforderung der K aus §§ 280 I, 241 II BGB....19
a) Mietverhältnis als Schuldverhältnis....19
b) Verletzung der Obhutspflicht, § 241 II BGB....19
c) Vertretenmüssen der T, §§ 280 I 2, 276 BGB....19
d) Ersatzfähiger Schaden, § 249 BGB....19
e) Entbehrlichkeit einer Fristsetzung zur Schadensbeseitigung....19
f) Zwischenergebnis zur Gegenforderung....20
2. Wirksame Aufrechnung, §§ 387 ff. BGB....20
a) Gegenseitigkeit von Haupt- und Gegenforderung, § 387 BGB....20
b) Gleichartigkeit infolge der Ersetzungsbefugnis, § 249 II 1 BGB....20
c) Erfüllbarkeit der Haupt- und Fälligkeit der Gegenforderung....21
d) Verjährung der Gegenforderung, §§ 548 I, 390, 215 BGB....21
e) Erklärung der Aufrechnung, § 388 S. 1 BGB....22
f) Wirkung der Aufrechnung, § 389 BGB....22
g) Zwischenergebnis zur Aufrechnung....22
III. Ergebnis zu Frage 3....22
D. Frage 4: Beseitigungsanspruch der N gegen K aus § 1004 I 1 BGB....22
I. Eigentum der N am Nachbargrundstück....22

II. Eigentumsbeeinträchtigung durch die Gebäudereste....22
1. Ursprüngliche Duldungspflicht nach § 912 I BGB....23
a) Überbau bei Errichtung eines Gebäudes....23
b) Weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit des Überbauenden....23
c) Kein sofortiger Widerspruch der N....23
d) Zwischenergebnis zu § 912 I BGB....24
e) Rechtsfolgen des entschuldigten Überbaus....24
2. Fortwirkung gegenüber den Rechtsnachfolgern V und K....24
3. Erlöschen der Duldungspflicht durch den Teilabriss....24
4. Eigentumslage an den Gebäuderesten....24
III. Verantwortlichkeit der K als Störerin....25
IV. Kein Ausschluss nach § 1004 II BGB....25
V. Ergebnis zu Frage 4....25

Literaturverzeichnis

Autor Buch

Sachverhalt

V ist Eigentümerin eines bebauten Grundstücks. Auf dem Grundstück befindet sich eine Doppelhaushälfte mit untergeordneter vermieteter Einliegerwohnung sowie ein kleiner Werkstattanbau. V beauftragt Maklerin A schriftlich mit dem Verkauf des Grundstücks. Vereinbart wird eine Provision von 3 % des Kaufpreises. A erstellt ein Exposé. Darin erklärt sie deutlich, dass ihre Maklertätigkeit nicht nur für die Verkäuferseite, sondern auch für die Käuferseite erfolgt (Doppeltätigkeit). Daher habe ein Käufer ebenfalls eine Provision von 3 % des Kaufpreises zu zahlen. K sieht das Exposé und meldet sich bei A. A und K schließen in den Geschäftsräumen der A schriftlich einen Maklervertrag nach einem Formular, welches A seit langem für ihre Kunden standardmäßig benutzt und die marktübliche 3 % Provision des Käufers vorsieht. Die Höhe der vom Verkäufer zu tragenden Provision ist in dem Formular nicht angegeben. K kennt das Grundstück bereits seit längerer Zeit. Sie hat beim Spazierengehen immer wieder ein Auge darauf geworfen und sieht es als interessantes Erwerbsobjekt zu privaten Wohnzwecken an. Von einer Verkaufsabsicht der V und vom Verkaufspreis erfährt K aber erst durch das Exposé. V und K verhandeln anschließend über den Kaufpreis, werden sich aber nicht einig und brechen die Verhandlungen zunächst ab. Nach vier Monaten nehmen sie wieder Kontakt auf und erzielen eine Einigung. K kauft das Grundstück schließlich von V mit notariell beurkundetem Kaufvertrag für EUR 1.000.000. Die Auflassung wird formgerecht erklärt, und K wird im Grundbuch als Eigentümerin eingetragen. Nun verlangt A von K EUR 30.000 Maklerprovision. K erklärt gegenüber A, sie wolle an den Maklervertrag nicht mehr gebunden sein. Sie habe zwar das Exposé einschließlich der Angabe zur Provisionspflicht gründlich gelesen, habe aber nicht gewusst, was die Provisionspflicht bedeute. K erklärt außerdem, sie werde allenfalls zahlen, wenn A den Maklervertrag mit V vorlegt. A teilt der K lediglich mit, V habe ebenfalls 3 % Provision geschuldet und gezahlt.

In der vermieteten Einliegerwohnung lebt seit sechs Jahren die 82-jährige T. T ärgert sich bereits seit ihrem Einzug über den allmorgendlichen Lärm eines angrenzenden Kindergartens. Dennoch zahlte sie in den ersten vier Jahren vorbehaltlos die volle vereinbarte Miete. Danach zog sie bei den Überweisungen der monatlichen Mietzahlungen eigenmächtig jeweils 40 % ab. Der Kindergarten war bereits vor dem Einzug der T in Betrieb und hält schon immer sämtliche Immissionsrichtwerte ein. Von beidem hatte die T beim Einzug auch Kenntnis. Nach dem Eigentumsübergang auf K zahlt T auch an K weiterhin nur die verminderte Miete. K lässt die Rückstände zunächst sechs Monate auflaufen und kündigt T schließlich schriftlich fristlos,

hilfsweise ordentlich wegen Zahlungsverzugs. Die Zahlungsrückstände werden im Schreiben richtig beziffert. Ein Hinweis auf den Sozialwiderspruch fehlt im Kündigungsschreiben. Da T sich noch am selben Tag weigert, auszuziehen, erhebt K am folgenden Tag in prozessrechtlich zulässiger Form Räumungsklage. Sieben Wochen nach Zustellung der Räumungsklage zahlt T sämtliche Mietrückstände nach. T schreibt der K per Brief, dass die Kündigung schon wegen ihres – der T – hohen Alters nicht rechtmäßig sei. Es liegen bei T keine gesundheitlichen Einschränkungen oder sonstigen Umstände vor, die einen Umzug unmöglich oder unzumutbar machen würden. Weitere acht Monate später fordert K von T erneut Räumung und Herausgabe der Wohnung.

Frage 1: Hat A gegen K einen Anspruch auf Zahlung von EUR 30.000?

Frage 2: Hat K gegen T einen Anspruch auf Räumung und Herausgabe der Wohnung?

T räumt die Wohnung schließlich doch und gibt sie an K zurück. Bei der Rückgabe der Wohnung entdeckt K erhebliche Beschädigungen an Böden und Türen, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch der Wohnung durch T zurückzuführen sind. Die Beseitigung dieser Schäden würde EUR 2.000 kosten. Acht Monate nach Rückgabe der Wohnung verlangt T von K Rückzahlung ihrer zu Beginn des Mietverhältnisses an V geleisteten Barkaution in Höhe von EUR 2.000, was dem Zweifachen der unveränderten Nettokaltmiete entspricht. K erklärt gegenüber T, sie behalte die Kaution wegen der verursachten Schäden ein. T gibt zwar zu, dass sie die Schäden pflichtwidrig und schuldhaft verursacht hat, wendet aber ein, dass K ihr diesbezüglich keine Frist zur Reparatur gesetzt hat.

Der Werkstattanbau auf dem Grundstück (Stammgrundstück) steht teilweise auf dem Nachbargrundstück, welches sich im Eigentum der N befindet. Errichtet wurde der Anbau durch den Vater der V, der damals Eigentümer des Stammgrundstücks war. Bei der Errichtung war dem Vater der V der Grenzverlauf nicht bekannt. Die Überbauung war trotz sorgfältiger Prüfung der verfügbaren Unterlagen für den Vater der V nicht erkennbar. N hatte der Errichtung des Werkstattanbaus zugesehen und erkannt – anders als der Vater der V –, dass Teile auf ihrem Grundstück stehen. Sie hat der Überbauung aber erst zwei Monate nach der Fertigstellung widersprochen. V wurde schließlich Alleinerbin ihres Vaters. Nachdem K das Grundstück von V erworben hat, lässt K den auf ihrem Grundstück befindlichen Teil des Werkstattanbaus abreißen. Die

auf dem Grundstück der N stehenden Gebäudeteile lässt K stehen. K meint, die Gebäudereste gehörten nun der N. N verlangt dagegen von K die Beseitigung der Reste.

Frage 3: Hat T gegen K einen Anspruch auf Rückzahlung der Kaution?

Frage 4: Kann N von K die Beseitigung der auf dem Grundstück der N verbliebenen Gebäudeteile verlangen?

Gutachten

A. Frage 1: Provisionsanspruch der A gegen K aus § 652 I 1 BGB[1]

A könnte gegen K einen Anspruch auf Zahlung eines Maklerlohns in Höhe von 30.000 € aus § 652 I 1 haben. Dies setzt einen wirksamen Maklervertrag, eine Nachweis- oder Vermittlungsleistung der A und den Abschluss des Hauptvertrags infolge dieser Tätigkeit voraus.

I. Entstehung des Anspruchs

Zunächst müsste der Anspruch entstanden sein.

1. Zustandekommen eines wirksamen Maklervertrags

Zwischen A und K müsste ein wirksamer Maklervertrag bestehen.

a) Einigung durch Angebot und Annahme, §§ 145 ff. BGB

Ein Vertrag kommt durch zwei inhaltlich übereinstimmende Willenserklärungen, Angebot und Annahme, gem. §§ 145 ff. zustande.[2]

aa) Angebot durch das Exposé, § 145 BGB

Zunächst könnte bereits das von A erstellte Exposé ein Angebot i.S.d. § 145 darstellen. Ein Angebot ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung, die alle vertragswesentlichen Bestandteile enthält.[3] Maßgeblich ist, ob aus Sicht eines objektiven Empfängers ein Rechtsbindungswille erkennbar ist, §§ 133, 157.[4] Das Exposé weist zwar auf die Käuferprovision von 3 % hin, richtet sich aber an einen unbestimmten Kreis potenzieller Käufer, sodass A sich erkennbar nicht gegenüber jedem Leser binden wollte. Es ist daher lediglich eine invitatio ad offerendum.[5]

bb) Vertragsschluss in den Geschäftsräumen der A

Angebot und Annahme könnten jedoch in den Geschäftsräumen der A erklärt worden sein. Nachdem sich K auf das Exposé hin bei A gemeldet hatte, schlossen beide dort schriftlich einen Maklervertrag und gaben damit übereinstimmende Willenserklärungen ab.

b) Einbeziehung und Wirksamkeit der Provisionsklausel

Die formularmäßige Käuferprovision von 3 % müsste nach Maßgabe der §§ 305 ff. wirksamer Vertragsbestandteil geworden sein.

---

1 Alle Normen, sofern nicht gesondert gekennzeichnet, entstammen dem BGB.
2 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …]
3 [Quelle einfügen]
4 [Quelle einfügen]
5 [Quelle einfügen]

aa) Anwendbarkeit der §§ 305 ff. BGB, § 310 III BGB

Zunächst müssten die §§ 305 ff. anwendbar sein; eine Bereichsausnahme nach § 310 IV greift nicht. Bei Verbraucherverträgen, also Verträgen zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher, gelten sie zudem mit den Maßgaben des § 310 III.[6] A handelt als gewerbliche Maklerin und damit als Unternehmerin i.S.d. § 14. K verfolgt mit dem Grundstückserwerb private Wohnzwecke und ist somit Verbraucherin i.S.d. § 13. Ein Verbrauchervertrag liegt vor.

bb) Provisionsklausel als AGB, § 305 I 1 BGB

Die Provisionsklausel müsste eine AGB sein. Erfasst sind nach § 305 I 1 vorformulierte Vertragsbedingungen, die für eine Vielzahl von Verträgen bestimmt sind und von einer Partei bei Vertragsschluss gestellt wer den.[7] Das Formular, das A seit Langem standardmäßig für ihre Kunden verwendet, enthält die vorformulierte Käuferprovision von 3 %, die nicht individuell ausgehandelt wurde. Die Provisionsklausel ist somit eine AGB; jedenfalls gilt sie gem. § 310 III Nr. 1 als von A gestellt.

cc) Einbeziehung in den Vertrag, § 305 II BGB

Die Klausel müsste ferner gem. § 305 II wirksam in den Vertrag einbezogen worden sein. Dafür muss der Verwender bei Vertragsschluss auf die AGB hinweisen und der anderen Partei die Möglichkeit verschaffen, in zumutbarer Weise von ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen; zudem muss diese mit ihrer Geltung einverstanden sein.[8] Die Klausel war unmittelbar im Text des schriftlichen Formularvertrags enthalten, den A der K vorlegte. K konnte sie daher zur Kenntnis nehmen und erklärte sich durch den Vertragsschluss mit ihr einverstanden; sie ist einbezogen.

dd) Keine vorrangige Individualabrede, § 305b BGB

Eine von der Klausel abweichende, gem. § 305b vorrangige Individualabrede zwischen A und K ist nicht ersichtlich.

ee) Keine überraschende Klausel, § 305c I BGB

Die Klausel dürfte nicht überraschend i.S.d. § 305c I sein. Dies setzt voraus, dass sie objektiv ungewöhnlich ist und der Vertragspartner sub-

6 [Quelle einfügen]
7 [Quelle einfügen]
8 [Quelle einfügen]

jektiv nicht mit ihr rechnen musste.[9] Objektiv ungewöhnlich ist sie, wenn sie deutlich von dem abweicht, was im redlichen Geschäftsverkehr üblicherweise zu erwarten ist.[10] Subjektiv überraschend ist sie, wenn ihr Inhalt erheblich von den berechtigten Erwartungen des Vertragspartners abweicht.[11] Die Käuferprovision von 3 % ist marktüblich. Zudem hatte A bereits im Exposé, das K gründlich gelesen hatte, deutlich auf ihre Doppeltätigkeit und die Käuferprovision hingewiesen. K musste daher mit der Klausel rechnen; sie ist nicht überraschend.

ff) Inhalts- und Transparenzkontrolle, § 307 BGB

Die Klausel müsste schließlich einer Inhaltskontrolle standhalten. Gem. § 307 III 1 unterliegen AGB dieser nur, soweit sie von Rechtsvorschrif ten abweichen oder diese ergänzen.[12] Preisabreden über die Hauptleistung sind mangels gesetzlicher Preisvorgaben grundsätzlich kontrollfrei.[13] Da die Höhe der Maklerprovision gesetzlich nicht festgelegt ist, stellt die Käuferprovision von 3 % eine kontrollfreie Preisabrede dar. Anwendbar bleibt nach § 307 III 2 allerdings das Transparenzgebot des § 307 I 2, wonach AGB klar und verständlich formuliert sein müssen.[14] Für K war eindeutig erkennbar, dass sie bei Abschluss des Kaufvertrags 3 % des Kaufpreises schuldet. Dass die Verkäuferprovision im Formular fehlt, berührt nicht die Klarheit der Käuferprovision, sondern allein die Überprüfbarkeit des § 656c I (dazu unter II.). Ein Verstoß gegen das Transparenzgebot liegt nicht vor.

gg) Zwischenergebnis zur Provisionsklausel

Die Provisionsklausel ist wirksamer Vertragsbestandteil geworden.

c) Anwendbarkeit der Sondervorschriften der §§ 656a ff. BGB

Weiterhin könnten die besonderen Vorschriften der §§ 656a ff. auf den Maklervertrag anwendbar sein.

aa) Verbrauchereigenschaft der K, § 656b BGB

K müsste Verbraucherin sein, da die §§ 656c, 656d gem. § 656b nur gelten, wenn der Käufer einer Wohnung oder eines Einfamilienhauses

9 [Quelle einfügen]
10 [Quelle einfügen]
11 [Quelle einfügen]
12 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …]
13 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …]
14 [Quelle einfügen]

Verbraucher i.S.d. § 13 ist.[15] Da K das Grundstück zu privaten Wohnzwecken erwirbt, ist dies der Fall (s.o.).

bb) Einordnung als Einfamilienhaus i.S.d. §§ 656a ff. BGB

Zudem müsste das Kaufobjekt ein Einfamilienhaus sein. Fraglich ist, ob die Doppelhaushälfte trotz der vermieteten Einliegerwohnung und des Werkstattanbaus noch als solches anzusehen ist. Ein Einfamilienhaus i.S.d. §§ 656a ff. ist ein Gebäude, das in erster Linie den Wohnzwecken der Mitglieder eines einzelnen Haushalts dient;[16] hierunter können auch Doppelhaushälften fallen.[17] Umstritten ist, nach welchem Maßstab dieser Wohnzweck zu bestimmen ist.[18] Nach einer Ansicht kommt es auf die objektive bauliche Beschaffenheit und die Verkehrsanschauung an. Hierfür spricht die Rechtssicherheit, da die Einordnung nicht von den Vorstellungen des einzelnen Erwerbers abhängt.[19] Nach anderer Ansicht ist der konkrete, für den Makler erkennbare Erwerbszweck des Käufers maßgeblich; angeführt wird insbesondere der Verbraucherschutzzweck der §§ 656a ff.[20] Der Streit kann dahinstehen, wenn beide Ansichten zum gleichen Ergebnis führen. Nach objektiver Betrachtung steht die Wohnnutzung der Doppelhaushälfte im Vordergrund. Die vermietete Einliegerwohnung ist ausdrücklich untergeordnet und der Werkstattanbau lediglich klein, sodass beide gegenüber der Nutzung durch einen Haushalt zurücktreten.[21] Auch nach dem Erwerbszweck liegt ein Einfamilienhaus vor, da K das Objekt zu privaten Wohnzwecken erwerben möchte. Dieser Zweck war für A bei einer privaten Interessentin, die eine Doppelhaushälfte erwerben will, auch erkennbar. Das Kaufobjekt ist somit ein Einfamilienhaus i.S.d. §§ 656a ff.

cc) Zwischenergebnis zur Anwendbarkeit

Der Anwendungsbereich der §§ 656a ff. ist eröffnet.

d) Einhaltung der Vorgaben der §§ 656a ff. BGB

Der Maklervertrag müsste den Anforderungen der §§ 656a ff. genügen.

---

15 [Quelle einfügen]
16 [Quelle einfügen]
17 [Quelle einfügen]
18 [Quelle einfügen]
19 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …]
20 [Quelle einfügen]
21 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …]

aa) Wahrung der Textform, § 656a BGB

Der Maklervertrag müsste gem. § 656a in Textform i.S.d. § 126b geschlossen worden sein.[22] Erforderlich ist eine lesbare Erklärung, die die Person des Erklärenden nennt und auf einem dauerhaften Datenträger abgegeben wird.[23] Der Maklervertrag zwischen A und K wurde schriftlich abgeschlossen. Die strengere Schriftform wahrt zugleich die Textform; § 656a ist eingehalten.

bb) Halbteilungsgrundsatz bei Doppeltätigkeit, § 656c I 1 BGB

Da A für beide Seiten tätig wurde, müsste sie zudem § 656c I 1 beachtet haben. Lässt sich ein Makler von beiden Parteien des Kaufvertrags einen Maklerlohn versprechen, darf dies danach nur in gleicher Höhe erfolgen (Halbteilungsgrundsatz).[24] Eine gleichzeitige Beauftragung ist nicht erforderlich; es genügt, dass der Makler nacheinander für beide Seiten tätig wird.[25] A wurde zunächst von V und anschließend, wie im Exposé angekündigt, von K beauftragt und vereinbarte mit beiden eine Provision von jeweils 3 % des Kaufpreises. § 656c I 1 ist damit eingehalten. K kann dies mangels Kenntnis des Vertrags zwischen A und V allerdings nicht überprüfen (dazu unter II.).

cc) Zwischenergebnis zu den §§ 656a ff.

Die Vorgaben der §§ 656a ff. sind gewahrt.

e) Widerruf des Maklervertrags, §§ 355 I, 312g I BGB

Die Erklärung der K, sie wolle an den Maklervertrag nicht mehr gebun den sein, könnte ein Widerruf gem. § 355 I sein. Dieser setzt ein gesetz liches Widerrufsrecht voraus. Ein solches steht dem Verbraucher gem. § 312g I nur bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen (§ 312b) und bei Fernabsatzverträgen (§ 312c) zu.[26] A und K schlossen den Maklervertrag bei gleichzeitiger Anwesenheit in den Geschäftsräumen der A, nachdem sich K auf das Exposé hin selbst an A gewandt hatte; auch § 312b I 1 Nr. 3 greift daher nicht, und ein Fernabsatzvertrag scheidet ebenfalls aus. K steht somit kein Widerrufsrecht zu.

---

22 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …]
23 [Quelle einfügen]
24 [Quelle einfügen]
25 [Quelle einfügen]
26 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …]

f) Kündigung des Maklervertrags

Die Erklärung der K könnte ferner als Kündigung des Maklervertrags auszulegen sein, §§ 133, 157. Eine Kündigung wirkt allerdings nur für die Zukunft und lässt den Provisionsanspruch für einen Hauptvertrag unberührt, der bereits vor ihrem Zugang geschlossen wurde.[27] K gab ihre Erklärung erst ab, nachdem sie das Grundstück von V gekauft und A die Provision verlangt hatte. Eine etwaige Kündigung stünde dem Anspruch daher nicht entgegen.

g) Nichtigkeit infolge Anfechtung, § 142 I BGB

Schließlich könnte der Maklervertrag gem. § 142 I als von Anfang an nichtig anzusehen sein, wenn K ihre auf seinen Abschluss gerichtete Willenserklärung wirksam angefochten hat.

aa) Erklärung der Anfechtung, § 143 I, II BGB

Zunächst müsste K die Anfechtung gegenüber A als ihrer Vertragspartnerin erklärt haben, § 143 I, II. Die Erklärung muss nicht ausdrücklich als Anfechtung bezeichnet werden;[28] es genügt, dass der Erklärende erkennbar macht, das Geschäft wegen eines Willensmangels nicht gelten lassen zu wollen.[29] Indem K gegenüber A erklärte, sie wolle an den Vertrag nicht mehr gebunden sein, weil sie die Bedeutung der Provisionspflicht nicht gekannt habe, hat sie die Anfechtung erklärt.

bb) Vorliegen eines Anfechtungsgrundes, § 119 I BGB

Daneben bedarf es eines Anfechtungsgrundes, wobei hier allein ein Irrtum nach § 119 I in Betracht kommt. Ein Erklärungsirrtum gem. § 119 I Alt. 2 liegt vor, wenn der Erklärende eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte, etwa weil er sich verspricht oder verschreibt.[30] Bei einem Inhaltsirrtum gem. § 119 I Alt. 1 weiß der Erklärende dagegen, was er äußerlich erklärt, irrt aber über die Bedeutung seiner Erklärung.[31] K hatte das Exposé gründlich gelesen und den Maklervertrag bewusst geschlossen; dass sie sich verschrieben oder etwas anderes erklären wollte, ist nicht ersichtlich. Ein Erklärungsirrtum

27 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …]
28 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …]
29 [Quelle einfügen]
30 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …]
31 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …]

scheidet aus. Ob ihre Aussage, sie habe nicht gewusst, „was die Provisi onspflicht bedeute“, einen Inhaltsirrtum begründet, hängt davon ab, ob ein beachtlicher Rechtsfolgenirrtum vorliegt.

cc) Rechtsfolgenirrtum als Inhaltsirrtum, § 119 I Alt. 1 BGB

K könnte einem beachtlichen Rechtsfolgenirrtum unterlegen sein. Ein solcher liegt vor, wenn das Rechtsgeschäft eine wesentlich andere als die vom Erklärenden vorgestellte Rechtsfolge auslöst.[32] Problematisch ist, wann ein solcher Irrtum als Inhaltsirrtum beachtlich und wann er bloß unbeachtlicher Motivirrtum ist.[33] Beachtlich ist er nur, wenn sich die Fehlvorstellung auf eine Rechtsfolge bezieht, die unmittelbarer Inhalt der Erklärung ist. Betrifft sie hingegen Rechtsfolgen, die kraft Gesetzes lediglich mittelbar an das Geschäft anknüpfen, ist sie unbeachtlich.[34] K wusste aufgrund des gründlich gelesenen Exposés, dass auch die Käuferseite 3 % des Kaufpreises zu zahlen hat, und unterzeichnete sodann einen Vertrag mit genau dieser Provisionsabrede. Die Zahlungs pflicht als unmittelbarer Erklärungsinhalt war ihr also bekannt; ihre erst nach der Zahlungsaufforderung geäußerte Unkenntnis betrifft allenfalls weitere gesetzliche Folgen dieser Verpflichtung. Es liegt daher nur ein unbeachtlicher Motivirrtum vor.

dd) Zwischenergebnis zur Anfechtung

Mangels Anfechtungsgrundes ist der Maklervertrag nicht gem. § 142 I nichtig. Zwischen A und K besteht ein wirksamer Maklervertrag.

2. Nachweis der Gelegenheit zum Vertragsschluss, § 652 I 1 BGB

A müsste ferner die geschuldete Maklerleistung erbracht haben. Hierfür genügt nach § 652 I 1 der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss des Hauptvertrags oder dessen Vermittlung.[35] Ein Nachweis liegt vor, wenn der Makler seinem Kunden die konkrete Möglichkeit zum Abschluss des angestrebten Hauptvertrags aufzeigt.[36] K nahm das Exposé der A zur Kenntnis, in dem das Grundstück zum Kauf angeboten wurde. Ei-

32 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …]
33 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …]
34 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …]
35 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …]
36 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …]

nem Nachweis könnte allerdings entgegenstehen, dass K das Grundstück von Spaziergängen bereits seit Längerem kannte. Die bloße Kenntnis des Objekts ist jedoch von der Kenntnis der konkreten Vertragsgelegenheit zu unterscheiden;[37] an Letzterer fehlt es, solange der Kunde nichts von der Verkaufsbereitschaft des Eigentümers weiß.[38] Von der Verkaufsabsicht der V und dem Kaufpreis erfuhr K erst durch das Exposé, sodass A ihr die Vertragsgelegenheit nachgewiesen hat.

3. Wirksamer Abschluss des Hauptvertrags

Weiterhin müsste der Hauptvertrag wirksam zustande gekommen sein. Maßgeblich ist der Abschluss des schuldrechtlichen Vertrags;[39] auf dessen Durchführung kommt es nicht an.[40] Der zwischen V und K über 1.000.000 € geschlossene Grundstückskaufvertrag (§ 433) wurde gem. § 311b I 1 notariell beurkundet und ist wirksam.

4. Ursächlichkeit der Maklertätigkeit

Der Hauptvertrag müsste ferner infolge der Nachweistätigkeit der A zustande gekommen sein, § 652 I 1.[41] Eine die Kausalität ausschließende Vorkenntnis bestand nicht, da K zwar das Grundstück, nicht aber die konkrete Verkaufsgelegenheit kannte (s.o.).[42] Fraglich ist jedoch, ob der Ursachenzusammenhang dadurch entfallen ist, dass V und K ihre Verhandlungen zunächst abbrachen und erst vier Monate später wieder aufnahmen. Eine bloß vorübergehende Unterbrechung der Verhandlungen genügt hierfür nicht.[43] Entscheidend ist, ob zwischen Maklerleistung und Vertragsschluss noch ein angemessener zeitlicher Zusammenhang besteht;[44] ein Abstand von bis zu einem Jahr kann dabei noch angemessen sein.[45] Hier lagen lediglich vier Monate zwischen Abbruch und Wiederaufnahme, und der Vertrag kam über genau das nachgewie-

37 [Quelle einfügen]
38 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …]
39 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …]
40 [Quelle einfügen]
41 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …]
42 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …]
43 [Quelle einfügen]
44 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …]
45 [Quelle einfügen]

sene Grundstück zustande; der Ursachenzusammenhang besteht fort.

5. Höhe der Provision

Schließlich müsste der Anspruch in Höhe von 30.000 € bestehen. A und K vereinbarten 3 % des Kaufpreises von 1.000.000 €, mithin 30.000 €.

6. Zwischenergebnis zur Entstehung

Der Provisionsanspruch der A ist entstanden.

II. Durchsetzbarkeit des Provisionsanspruchs

Der Provisionsanspruch müsste zudem durchsetzbar sein. Daran bestehen Zweifel, weil K ihre Zahlung von der Vorlage des Maklervertrags zwischen A und V abhängig macht.

1. Auskunftsanspruch der K aus § 242 BGB

K könnte gegen A ein Anspruch auf Auskunft über die mit V vereinbarte Provision aus § 242 zustehen, da sie mangels Kenntnis des Vertrags zwischen A und V nicht überprüfen kann, ob A den Halbteilungsgrundsatz des § 656c I 1 eingehalten hat. § 656c enthält keinen ausdrücklichen Auskunftsanspruch des Maklerkunden, weshalb umstritten ist, ob sich ein solcher aus § 242 ergeben kann.[46] Teilweise wird ein solcher Anspruch bejaht, wenn der Maklerkunde zur Kontrolle der Halbteilung auf Informationen des Maklers angewiesen ist.[47] Nach anderer Ansicht fehlt es mangels gesetzlicher Regelung an einer Grundlage.[48] Für die erstgenannte Ansicht spricht, dass K ohne die Information nicht prüfen kann, ob der zwingende § 656c I 1 eingehalten ist, während A die Auskunft ohne unbillige Belastung erteilen kann. K hat daher einen Auskunftsanspruch aus § 242. Mit ihrer bloßen Mitteilung, V habe ebenfalls 3 % geschuldet und gezahlt, hat A zwar Auskunft erteilt; überprüfen kann K diese Behauptung aber nicht. Fraglich ist daher, ob K darüber hinaus Einsicht in den Vertrag verlangen kann.

2. Einsichtsanspruch der K aus § 810 Fall 2 BGB

K könnte gegen A ein Anspruch auf Einsicht in den Maklervertrag zwischen A und V aus § 810 Fall 2 zustehen.

a) Maklervertrag als Urkunde

Der Maklervertrag zwischen A und V müsste eine Urkunde sein. Ur-

---

46 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …]
47 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …]
48 [Quelle einfügen]

kunde i.S.d. § 810 ist jede durch Niederschrift verkörperte Gedankener klärung, die Aussagen über ein Rechtsgeschäft oder Rechtsverhältnis enthält.[49] A und V schlossen den Maklervertrag schriftlich und hielten darin die Provision der V von 3 % fest. Er ist somit eine Urkunde.

b) Bezug der Urkunde zu einem Rechtsverhältnis der K

Die Urkunde müsste ein Rechtsverhältnis beurkunden, an dem K beteiligt ist.[50] Problematisch ist, dass K nicht Partei des Vertrags zwischen A und V ist. § 810 Fall 2 verlangt jedoch nicht, dass die Urkunde das Rechtsverhältnis des Anspruchstellers unmittelbar dokumentiert;[51] es genügt eine objektive und unmittelbare Beziehung der Urkunde zu diesem Rechtsverhältnis.[52] Wegen der Doppeltätigkeit der A hängt die Wirksamkeit der Provisionsabrede zwischen A und K gem. § 656c I 1 davon ab, dass auch V eine Provision in gleicher Höhe versprochen hat. Gerade dies dokumentiert der Vertrag zwischen A und V. Die erforderliche Beziehung zum Rechtsverhältnis zwischen A und K besteht.

c) Rechtliches Interesse an der Einsichtnahme

Weiterhin bedarf es eines rechtlichen Interesses der K an der Einsichtnahme. Ein solches besteht, wenn die Einsicht zur Förderung, Erhaltung oder Verteidigung rechtlich geschützter Interessen erforderlich ist.[53] Eine bloße Ausforschung aufgrund vager Vermutungen genügt hingegen nicht.[54] Ob die Forderung der A über 30.000 € besteht, hängt nach § 656c von der Provisionsabrede mit V ab, die A nicht vorlegt, sondern lediglich behauptet. K will damit keine bloßen Vermutungen ausforschen, sondern eine für ihre eigene Zahlungspflicht erhebliche Voraussetzung überprüfen. Ein rechtliches Interesse liegt vor.

d) Besitz der Urkunde durch A

Schließlich müsste sich die Urkunde im Besitz der A befinden.[55] A ist selbst Partei des Vertrags mit V. Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte ist davon auszugehen, dass sie die Urkunde besitzt.

---

49 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …]
50 [Quelle einfügen]
51 [Quelle einfügen]
52 [Quelle einfügen]
53 [Quelle einfügen]
54 [Quelle einfügen]
55 [Quelle einfügen]

e) Zwischenergebnis zu § 810 BGB

K kann von A gem. § 810 Fall 2 die Gestattung der Einsicht in den Mak lervertrag zwischen A und V verlangen.

3. Einrede des Zurückbehaltungsrechts, § 273 I BGB

K könnte die Zahlung gem. § 273 I bis zur Gewährung der Einsicht ver weigern. Ihre Erklärung, sie werde allenfalls nach Vorlage des Vertrags mit V zahlen, ist als Geltendmachung dieses Rechts zu verstehen.

a) Gegenseitigkeit der Ansprüche

Zunächst müsste K als Schuldnerin der Provision ein Gegenanspruch gegen A als Gläubigerin zustehen.[56] Der Provisionsforderung der A aus § 652 I 1 steht der Einsichtsanspruch der K aus § 810 Fall 2 in umgekehrter Richtung gegenüber.

b) Konnexität der Ansprüche

Der Gegenanspruch müsste aus demselben rechtlichen Verhältnis stam men.[57] Dass beide Ansprüche demselben Vertrag entspringen, ist nicht erforderlich; ausreichend ist ein enger tatsächlicher und wirtschaftlicher Zusammenhang.[58] Der Einsichtsanspruch soll gerade klären, ob A die Provision von K nach § 656c I 1 verlangen kann. Beide Ansprüche wur zeln damit in der Doppeltätigkeit der A und hängen eng zusammen.

c) Fälligkeit und Durchsetzbarkeit des Gegenanspruchs

Der Gegenanspruch müsste wirksam, fällig und durchsetzbar sein.[59] Der Einsichtsanspruch der K ist entstanden und mangels abweichender Bestimmung sofort fällig, § 271 I; K hat die Vorlage bereits verlangt. Einreden der A sind nicht ersichtlich.

d) Rechtsfolge des Zurückbehaltungsrechts, § 274 I BGB

Fraglich ist, welche Wirkung das Zurückbehaltungsrecht hier entfaltet. Grundsätzlich führt es gem. § 274 I nur dazu, dass der Schuldner Zug um Zug gegen Erfüllung des Gegenanspruchs zu leisten hat.[60] Anders liegt es ausnahmsweise, wenn Haupt- und Gegenanspruch in einem

56 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …]
57 [Quelle einfügen]
58 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …]
59 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …]
60 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …]

besonderen Abhängigkeitsverhältnis stehen und der Gegenanspruch gerade der Überprüfung der Hauptforderung dient. Dann kann der Gläubiger die Leistung vorerst überhaupt nicht verlangen, sodass eine Zahlungsklage nicht zu einer Verurteilung Zug um Zug, sondern zur Abweisung führen würde.[61] K benötigt die Einsicht, um zu prüfen, ob A § 656c I 1 eingehalten hat. Hätte V keine Provision in gleicher Höhe versprochen, wäre die Provisionsabrede mit K gem. § 656c II 1 unwirk sam.[62] A kann die Zahlung daher derzeit nicht verlangen, solange sie K die Einsicht nicht gewährt.

e) Zwischenergebnis zu § 273 BGB

K steht ein Zurückbehaltungsrecht gem. § 273 I zu.

III. Ergebnis zu Frage 1

Der Provisionsanspruch der A gegen K über 30.000 € aus § 652 I 1 ist zwar entstanden. Solange A der K keine Einsicht in den Maklervertrag mit V gewährt, kann sie ihn wegen des Zurückbehaltungsrechts der K aus § 273 I derzeit aber nicht durchsetzen.

B. Frage 2: Räumungs- und Herausgabeansprüche der K gegen T

I. Räumungsanspruch der K gegen T aus § 546 I BGB

K könnte von T gem. § 546 I die Räumung und Herausgabe der Einliegerwohnung verlangen. Hierfür müsste zwischen K und T ein Mietverhältnis bestanden haben, das beendet ist.

1. Eintritt der K in das Mietverhältnis, § 566 I BGB

Zunächst müsste zwischen K und T ein Mietverhältnis bestanden haben. T hatte die Wohnung ursprünglich von V gemietet; K könnte aber gem. § 566 I eingetreten sein. Danach tritt der Erwerber vermieteten Wohnraums, der nach der Überlassung veräußert wird, anstelle des Ver mieters in das Mietverhältnis ein,[63] wobei Veräußerung die Übertragung des Eigentums meint.[64] T bewohnte die Wohnung bereits, als K das Grundstück durch Auflassung und Eintragung (§§ 873 I, 925) erwarb. K ist damit in das Mietverhältnis eingetreten.

---

61 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …]
62 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …]
63 [Quelle einfügen]
64 [Quelle einfügen]

2. Wirksame Beendigung des Mietverhältnisses

Das Mietverhältnis müsste beendet worden sein. K kündigte schriftlich fristlos und hilfsweise ordentlich wegen Zahlungsverzugs.

a) Außerordentliche fristlose Kündigung, § 543 I, II 1 Nr. 3 BGB

Das Mietverhältnis könnte bereits durch die fristlose Kündigung beendet worden sein. Diese setzt gem. § 543 I 1 einen wichtigen Grund voraus. Ein solcher liegt nach § 543 I 2 vor, wenn dem Kündigenden unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls und der Interessen beider Vertragsparteien die Fortsetzung des Mietverhältnisses bis zu dessen regulärer Beendigung nicht zuzumuten ist.[65] Für den Zahlungsverzug enthält § 543 II 1 Nr. 3 besondere Kündigungstatbestände.[66] Die schriftlich (§ 568 I) erklärte Kündigung nennt mit den zutreffend bezifferten Rückständen zugleich ihren Grund, § 569 IV.

aa) Mietrückstand und Minderungsrecht, §§ 536, 536b BGB

Zunächst müsste T mit der Miete in Rückstand geraten sein. Dies wäre nicht der Fall, wenn sie gem. § 536 I zur Minderung wegen des Kindergartenlärms berechtigt war. Ein Mangel i.S.d. § 536 I ist jede für den Mieter nachteilige Abweichung der tatsächlichen von der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit, die die Tauglichkeit zum vertragsgemäßen Gebrauch beeinträchtigt.[67] Auch von einem Nachbargrundstück ausgehende Geräusche können einen Mangel begründen.[68] Fehlt eine Beschaffenheitsvereinbarung, ist nach den Umständen des Einzelfalls zu bestimmen, welche Belastung der Mieter hinzunehmen hat.[69] Muss der Vermieter die Immissionen selbst gem. § 906 entschädigungslos dulden, begründen sie regelmäßig keinen Mangel.[70] Eine besondere Vereinbarung zwischen V und T über die Geräuschbelastung ist nicht ersichtlich. Der Kindergarten war bereits bei Einzug der T in Betrieb und hält seit jeher sämtliche Immissionsrichtwerte ein, sodass nach § 906 I 2 in der Regel nur eine unwesentliche Beeinträchtigung vorliegt. Die Geräusche sind daher als zulässige Immissionen hinzunehmen; ein

65 [Quelle einfügen]
66 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …]
67 [Quelle einfügen]
68 [Quelle einfügen]
69 [Quelle einfügen]
70 [Quelle einfügen]

Mangel liegt nicht vor.[71] Selbst bei Annahme eines Mangels wäre die Minderung gem. § 536b S. 1 ausgeschlossen, da der Mieter, der den Mangel bei Vertragsschluss kennt, keine Rechte aus §§ 536, 536a hat.[72] T kannte den Betrieb des Kindergartens bereits bei ihrem Einzug. Ob sie ein Minderungsrecht zudem durch die vierjährige vorbehaltlose Zahlung verloren hätte, kann offenbleiben. T schuldete somit die volle Miete; durch die Kürzung um 40 % entstanden Rückstände.

bb) Verzug mit zwei Monatsmieten, § 543 II 1 Nr. 3 lit. b BGB

T müsste in dem von § 543 II 1 Nr. 3 lit. b vorausgesetzten Umfang in Verzug geraten sein. Danach muss der Mieter in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit einem Betrag in Verzug sein, der die Miete für zwei Monate erreicht.[73] Die Miete ist gem. § 556b I spätestens bis zum dritten Werktag des Monats zu entrichten, sodass es gem. § 286 II Nr. 1 keiner Mahnung bedurfte.[74] Ihr Irrtum über ein Minderungsrecht schließt das Vertretenmüssen (§ 286 IV) nicht aus, da ein Rechtsirrtum nur bei Unvermeidbarkeit entlastet, wofür nichts ersichtlich ist.[75] Nach dem Eigentumsübergang zahlte T an K sechs Monate lang jeweils nur 60 % der Miete. Maßgeblich sind allein diese Rückstände, da K gem. § 566 I nur in die während der Dauer ihres Eigentums entstehenden Rechte eintritt; frühere Rückstände stehen weiterhin V zu.[76] Der Rückstand erstreckt sich damit über mehr als zwei Termine und beläuft sich auf 6 × 40 % = 2,4 Monatsmieten. Dass K die Rückstände zunächst sechs Monate auflaufen ließ, steht der Kündigung nicht entgegen, da die §§ 543, 569 die Kündigung wegen Zahlungsverzugs abschließend regeln und § 314 III daher keine Anwendung findet.[77] Die Voraussetzungen des § 543 II 1 Nr. 3 lit. b liegen vor.

cc) Keine Abmahnung erforderlich, § 543 III 2 Nr. 3 BGB

Einer Abmahnung, die § 543 III 1 grundsätzlich verlangt,[78] bedurfte es

71 [Quelle einfügen]
72 [Quelle einfügen]
73 [Quelle einfügen]
74 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …]
75 [Quelle einfügen]
76 [Quelle einfügen]
77 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …]
78 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …]

gem. § 543 III 2 Nr. 3 bei Zahlungsverzug nicht.[79]

dd) Unwirksamkeit durch Schonfristzahlung, § 569 III Nr. 2 BGB

Die Kündigung könnte jedoch gem. § 569 III Nr. 2 S. 1 unwirksam geworden sein. Danach wird eine auf § 543 II 1 Nr. 3 gestützte Kündigung unwirksam, wenn der Vermieter hinsichtlich der fälligen Miete und der fälligen Entschädigung nach § 546a I befriedigt wird.[80] Dies muss spätestens bis zum Ablauf von zwei Monaten nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Räumungsanspruchs geschehen. T beglich sämtliche Rückstände sieben Wochen nach Zustellung der Räumungsklage, mit der die Rechtshängigkeit eintrat (§§ 253 I, 261 I ZPO), und damit innerhalb der Zweimonatsfrist. Mangels gegenteiliger Angaben ist davon auszugehen, dass die Zahlung auch die bis dahin fällige Nutzungsentschädigung nach § 546a I umfasste, sodass K vollständig befriedigt wurde. Ein Ausschluss nach § 569 III Nr. 2 S. 2 ist nicht ersichtlich. Die fristlose Kündigung hat ihre Wirkung damit nachträglich verloren.

b) Hilfsweise ausgesprochene ordentliche Kündigung, § 573 BGB

Das Mietverhältnis könnte aber durch die hilfsweise ausgesprochene ordentliche Kündigung nach § 573 geendet haben.

aa) Zulässigkeit und Eintritt der Bedingung

Fraglich ist zunächst, ob K die ordentliche Kündigung unter einer Bedingung erklären durfte. Als einseitiges Gestaltungsrecht ist die Kündigung grundsätzlich bedingungsfeindlich, da der Empfänger Klarheit über die Rechtslage benötigt.[81] Zulässig ist allerdings eine Bedingung, deren Eintritt allein von der rechtlichen Beurteilung abhängt (Rechtsbedingung), weil sie für den Empfänger keine Ungewissheit schafft.[82] Die ordentliche Kündigung sollte nur für den Fall gelten, dass die fristlose Kündigung das Mietverhältnis nicht beendet. Für T war damit eindeutig erkennbar, dass K das Mietverhältnis jedenfalls beenden will. Die Bedingung ist zudem eingetreten, da die fristlose Kündigung gem. § 569 III Nr. 2 unwirksam geworden ist.

bb) Berechtigtes Interesse der K, § 573 I 1, II Nr. 1 BGB

K müsste ein berechtigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhält

79 [Quelle einfügen]
80 [Quelle einfügen]
81 [Quelle einfügen]
82 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …]

nisses gehabt haben, § 573 I 1. Ein solches liegt nach § 573 II Nr. 1 ins besondere vor, wenn der Mieter seine vertraglichen Pflichten schuldhaft nicht unerheblich verletzt hat.[83] T kürzte die Miete über sechs Monate unberechtigt und schuldhaft (s.o.); ein Rückstand von 2,4 Monatsmieten ist nicht unerheblich. K hat daher ein berechtigtes Interesse.

cc) Schonfristzahlung und ordentliche Kündigung

Fraglich ist, ob die Nachzahlung auch die ordentliche Kündigung unwirksam macht. § 569 III Nr. 2 ordnet die Unwirksamkeit ausdrücklich nur für die außerordentliche fristlose Kündigung an.[84] Auf eine daneben erklärte ordentliche Kündigung erstreckt sich die Vorschrift nicht.[85] Die rechtzeitige Nachzahlung der T beseitigt die ordentliche Kündigung folglich nicht. Sie kann allenfalls bei der Gewichtung der Pflichtverletzung im Rahmen des § 573 II Nr. 1 zugunsten des Mieters berücksichtigt werden.[86] T hatte die Miete aber sechs Monate lang eigenmächtig gekürzt und erst nach Klageerhebung nachgezahlt, sodass das berechtigte Interesse der K bestehen bleibt.

dd) Einhaltung der Kündigungsfrist, § 573c I BGB

Weiterhin müsste die Kündigungsfrist eingehalten sein. Gem. § 573c I 2 verlängert sich die Frist für den Vermieter nach fünf Jahren seit der Überlassung des Wohnraums um drei Monate.[87] T wohnte bereits seit sechs Jahren in der Wohnung, sodass eine Frist von sechs Monaten galt. Wann die Kündigung genau zuging, ist unbekannt; als K die Räumung acht Monate später erneut verlangte, war die Frist jedenfalls abgelaufen und das Mietverhältnis beendet.

ee) Form und Begründung, §§ 568 I, 573 III BGB

Die Kündigung müsste zudem formgerecht erklärt und begründet worden sein. Gem. § 568 I bedarf sie der Schriftform, also der eigenhändigen Unterschrift des Kündigenden, § 126 I.[88] Zudem sind die Gründe für das berechtigte Interesse gem. § 573 III 1 im Kündigungsschreiben anzugeben. K kündigte schriftlich und bezifferte die Rückstände im Schreiben zutreffend; Form und Begründung sind gewahrt.

---

83 [Quelle einfügen]
84 [Quelle einfügen]
85 [Quelle einfügen]
86 [Quelle einfügen]
87 [Quelle einfügen]
88 [Quelle einfügen]

ff) Sozialwiderspruch der T, §§ 574 ff. BGB

T könnte der Kündigung gem. § 574 I 1 widersprechen und die Fortsetzung des Mietverhältnisses verlangen, wenn dessen Beendigung für sie eine nicht zu rechtfertigende Härte bedeuten würde. Ihren Brief, die Kündigung sei wegen ihres hohen Alters nicht rechtmäßig, kann man als schriftlichen Widerspruch i.S.d. § 574b I 1 auslegen. Ob der Widerspruch bereits nach § 574 I 2 ausgeschlossen ist, weil ein Grund zur fristlosen Kündigung vorlag, kann offenbleiben, wenn es jedenfalls an einer Härte fehlt. Zwar fließt ein hohes Lebensalter in die Abwägung ein;[89] für sich genommen begründet es jedoch keine Härte i.S.d. § 574 I.[90] Maßgeblich sind vielmehr die konkreten Folgen eines Umzugs für den Mieter.[91] Bei der 82-jährigen T bestehen weder gesundheitliche Einschränkungen noch sonstige Umstände, die ihr einen Umzug unmöglich oder unzumutbar machen. Eine Härte i.S.d. § 574 I liegt daher nicht vor. Der fehlende Hinweis auf den Sozialwiderspruch (§ 568 II) führt nicht zur Unwirksamkeit der Kündigung,[92] sondern hat gem. § 574b II 2 nur zur Folge, dass T den Widerspruch noch im ersten Termin des Räumungsrechtsstreits erklären kann.[93] Mangels Härte bliebe ein Widerspruch der T aber in jedem Fall erfolglos.

gg) Zwischenergebnis zur ordentlichen Kündigung

Die hilfsweise erklärte ordentliche Kündigung ist wirksam und hat das Mietverhältnis mit Ablauf der Kündigungsfrist beendet.

3. Ergebnis zum Räumungsanspruch

Nach Beendigung des Mietverhältnisses ist T gem. § 546 I verpflichtet, die Einliegerwohnung an K zu räumen und herauszugeben.

II. Herausgabeanspruch der K gegen T aus § 985 BGB

Daneben könnte K gegen T ein Anspruch auf Herausgabe der Einlieger wohnung aus § 985 zustehen.

1. Eigentum der K am Grundstück

K müsste Eigentümerin sein. Durch Auflassung und Eintragung (§§ 873 I, 925) erwarb sie das Grundstück und gem. §§ 93, 94 I zugleich das

89 [Quelle einfügen]
90 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …]
91 [Quelle einfügen]
92 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …]
93 [Quelle einfügen]

Gebäude samt Einliegerwohnung.

2. Besitz der T an der Wohnung

T müsste Besitzerin sein. Als Bewohnerin der Einliegerwohnung übt sie die tatsächliche Gewalt aus und ist unmittelbare Besitzerin, § 854 I.

3. Fehlendes Besitzrecht der T, § 986 I BGB

T dürfte K gegenüber kein Recht zum Besitz zustehen, § 986 I. Ein solches könnte allein aus dem Mietverhältnis folgen, das jedoch beendet ist; T ist daher nicht zum Besitz berechtigt.

4. Ergebnis zu § 985 BGB

K kann die Herausgabe der Wohnung auch gem. § 985 verlangen.

C. Frage 3: Kautionsrückzahlungsanspruch der T gegen K aus der Kautionsabrede i.V.m. § 566a S. 1 BGB

T könnte von K die Rückzahlung der an V geleisteten Kaution in Höhe von 2.000 € aus der Kautionsabrede i.V.m. § 566a S. 1 verlangen.

I. Entstehung des Rückzahlungsanspruchs

Zunächst müsste der Rückzahlungsanspruch entstanden sein.

1. Wirksame Kautionsabrede zwischen V und T, § 551 BGB

Erforderlich ist eine wirksame Kautionsabrede zwischen V und T. Die vereinbarte Barkaution von 2.000 € entspricht dem Zweifachen der Net tokaltmiete und hält damit die Höchstgrenze des § 551 I von drei Monatsmieten ohne Betriebskosten ein.[94] Die Abrede ist wirksam.

2. Übergang der Rückgewährpflicht auf K, § 566a S. 1 BGB

Die Pflicht zur Rückgewähr der Kaution müsste auf K übergegangen sein. Gem. § 566a S. 1 tritt der Erwerber in die Rechte und Pflichten ein, die durch die vom Mieter geleistete Sicherheit begründet worden sind.[95] Zur Rückgewähr der von T an V geleisteten Kaution ist daher K verpflichtet, soweit sie diese nicht für eigene Ansprüche verwenden darf.

3. Beendigung des Mietverhältnisses und Rückgabe der Wohnung

Zudem müsste das Mietverhältnis beendet und die Wohnung zurückgegeben sein. Beides ist nach der ordentlichen Kündigung (s. Frage 2) und der Räumung durch T der Fall.

---

94 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …]

95 [Quelle einfügen]

4. Zwischenergebnis zum Rückzahlungsanspruch

Der Rückzahlungsanspruch der T ist zunächst entstanden.

II. Erlöschen durch Aufrechnung, § 389 BGB

Der Rückzahlungsanspruch könnte jedoch infolge einer Aufrechnung der K gem. § 389 erloschen sein.

1. Gegenforderung der K aus §§ 280 I, 241 II BGB

K könnte gegen T wegen der Schäden an Böden und Türen ein Schadensersatzanspruch über 2.000 € aus §§ 280 I, 241 II zustehen.

a) Mietverhältnis als Schuldverhältnis

Zwischen K und T müsste ein Schuldverhältnis bestanden haben; dies ist das gem. § 566 I übergegangene Mietverhältnis. Da K nur in die während ihres Eigentums entstehenden Rechte eintritt (s. Frage 2), ist mangels gegenteiliger Angaben davon auszugehen, dass T die Schäden in dieser Zeit verursachte; andernfalls stünde der Anspruch der V zu.

b) Verletzung der Obhutspflicht, § 241 II BGB

T müsste eine Pflicht aus dem Mietverhältnis verletzt haben. Aus § 241 II folgt für den Mieter die Pflicht, die Mietsache schonend zu behandeln und Beschädigungen zu vermeiden, die über den vertragsgemäßen Gebrauch hinausgehen.[96] Durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigte T Böden und Türen erheblich und verletzte so ihre Obhutspflicht.

c) Vertretenmüssen der T, §§ 280 I 2, 276 BGB

Das Vertretenmüssen der T wird gem. § 280 I 2 vermutet; zudem räumt sie ein, die Schäden pflichtwidrig und schuldhaft verursacht zu haben.

d) Ersatzfähiger Schaden, § 249 BGB

Der K müsste durch die Pflichtverletzung ein ersatzfähiger Schaden entstanden sein. Die Beschädigungen an Böden und Türen mindern den Wert der Mietsache; ihre Beseitigung würde 2.000 € kosten.

e) Entbehrlichkeit einer Fristsetzung zur Schadensbeseitigung

Fraglich ist, ob der Anspruch eine vorherige Fristsetzung voraussetzt, wie T einwendet. Eine Fristsetzung ist gem. § 281 I 1 nur erforderlich, wenn wegen der Verletzung einer Leistungspflicht Schadensersatz statt der Leistung verlangt wird.[97] Die Pflicht des Mieters, die Mietsache schonend zu behandeln, ist keine Leistungspflicht, sondern eine nicht

96 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …]
97 [Quelle einfügen]

leistungsbezogene Nebenpflicht i.S.d. § 241 II.[98] Ihre Verletzung begründet einen Anspruch auf Schadensersatz neben der Leistung unmittelbar aus § 280 I, für den das Gesetz keine Fristsetzung vorsieht.[99] Der Geschädigte kann daher nach seiner Wahl gem. § 249 I Herstellung oder gem. § 249 II 1 sofort den erforderlichen Geldbetrag verlangen, ohne dem Schädiger zuvor Gelegenheit zur eigenen Reparatur geben zu müssen.[100] Da K Ersatz für bereits entstandene Schäden verlangt, bedurfte es keiner Fristsetzung; der Einwand der T greift nicht durch.

f) Zwischenergebnis zur Gegenforderung

K hat gegen T einen Anspruch auf 2.000 € aus §§ 280 I, 241 II.

2. Wirksame Aufrechnung, §§ 387 ff. BGB

Mit diesem Anspruch könnte K gegen den Kautionsrückzahlungsanspruch der T wirksam aufgerechnet haben. Dies setzt eine Aufrechnungslage i.S.d. § 387, das Fehlen von Ausschlussgründen und eine Aufrechnungserklärung gem. § 388 voraus.

a) Gegenseitigkeit von Haupt- und Gegenforderung, § 387 BGB

Die Forderungen müssten zwischen denselben Personen in umgekehrter Richtung bestehen.[101] K schuldet T die Kaution, T der K Schadensersatz; die Forderungen sind gegenseitig.

b) Gleichartigkeit infolge der Ersetzungsbefugnis, § 249 II 1 BGB

Weiterhin müssten Haupt- und Gegenforderung ihrem Gegenstand nach gleichartig sein.[102] Der Rückzahlungsanspruch ist auf Geld gerichtet, der Schadensersatzanspruch nach § 249 I hingegen zunächst auf Herstellung.[103] Bei der Beschädigung einer Sache kann der Gläubiger allerdings gem. § 249 II 1 statt der Herstellung den dafür erforderlichen Geldbetrag verlangen.[104] Diese Ersetzungsbefugnis muss er ausüben, damit der Anspruch als Geldforderung geltend gemacht werden kann.[105] Mit ihrer Erklärung, sie behalte die Kaution wegen der Schäden ein, verlangte K Geld statt Reparatur und übte damit die Ersetzungsbe-

98 [Quelle einfügen]
99 [Quelle einfügen]
100 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …]
101 [Quelle einfügen]
102 [Quelle einfügen]
103 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …]
104 [Quelle einfügen]
105 [Quelle einfügen]

fugnis konkludent aus.[106] Die Forderungen sind somit gleichartig.

c) Erfüllbarkeit der Haupt- und Fälligkeit der Gegenforderung

Die Hauptforderung müsste erfüllbar, die Gegenforderung fällig sein.[107] Der Kautionsrückzahlungsanspruch ist mit Beendigung des Mietverhältnisses erfüllbar. Fällig wird er erst, wenn der Vermieter nach einer angemessenen Prüfungs- und Abrechnungsfrist überblicken kann, ob er die Kaution für eigene Ansprüche benötigt; eine feste Frist besteht nicht.[108] Als T die Rückzahlung acht Monate nach Rückgabe verlangte, war diese Frist jedenfalls abgelaufen, zumal K die Schäden bereits bei der Rückgabe festgestellt hatte. Der Schadensersatzanspruch der K war mit Eintritt des Schadens fällig, § 271 I.

d) Verjährung der Gegenforderung, §§ 548 I, 390, 215 BGB

Die Gegenforderung dürfte zudem nicht einredebehaftet sein. Gem. § 390 kann mit einer Forderung, der eine Einrede entgegensteht, nicht aufgerechnet werden; bereits das Bestehen der Einrede genügt.[109] Ersatzansprüche des Vermieters wegen Verschlechterungen der Mietsache verjähren gem. § 548 I 1 in sechs Monaten, beginnend mit der Rückgabe der Mietsache, § 548 I 2.[110] Als K acht Monate nach Rückgabe erklärte, die Kaution einzubehalten, war der Anspruch daher verjährt. Gem. § 215 schließt die Verjährung die Aufrechnung jedoch nicht aus, wenn der Anspruch in dem Zeitpunkt noch nicht verjährt war, in dem erstmals aufgerechnet werden konnte.[111] Problematisch ist, dass die Forderungen erst durch die Ausübung der Ersetzungsbefugnis gleichartig wurden und K diese erst nach Ablauf der Verjährungsfrist ausübte. Nach ihrem Sicherungszweck ist die Barkautionsabrede aber so auszulegen, dass der Vermieter die Ersetzungsbefugnis erst im Rahmen der Kautionsabrechnung ausüben muss.[112] Denn die Barkaution dient gerade dazu, dem Vermieter nach Mietende einen unkomplizierten Zugriff zur Befriedigung seiner Ansprüche zu verschaffen.[113] Die

106 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …]
107 [Quelle einfügen]
108 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …]
109 [Quelle einfügen]
110 [Quelle einfügen]
111 [Quelle einfügen]
112 [Quelle einfügen]
113 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …]

Forderungen standen sich daher schon bei Rückgabe der Wohnung und damit vor Eintritt der Verjährung aufrechenbar gegenüber; gem. § 215 hindert die Verjährung die Aufrechnung nicht.

e) Erklärung der Aufrechnung, § 388 S. 1 BGB

K müsste die Aufrechnung gem. § 388 S. 1 gegenüber T erklärt haben. Eine ausdrückliche Bezeichnung als Aufrechnung ist nicht erforderlich;[114] es genügt, dass der Wille, die eigene Forderung mit der fremden zu verrechnen, für den Empfänger erkennbar ist.[115] Aus Sicht der T (§§ 133, 157) bringt die Erklärung der K, sie behalte die Kaution wegen der Schäden ein, gerade diesen Verrechnungswillen zum Ausdruck; die Aufrechnung ist erklärt.

f) Wirkung der Aufrechnung, § 389 BGB

Gem. § 389 gelten die Forderungen, soweit sie sich decken, als in dem Zeitpunkt erloschen, in dem sie sich erstmals aufrechenbar gegenüberstanden. Beide betragen 2.000 € und erlöschen daher vollständig.

g) Zwischenergebnis zur Aufrechnung

Der Rückzahlungsanspruch der T ist durch Aufrechnung erloschen.

III. Ergebnis zu Frage 3

T hat gegen K keinen Anspruch auf Rückzahlung der Mietkaution.

D. Frage 4: Beseitigungsanspruch der N gegen K aus § 1004 I 1 BGB

N könnte gegen K einen Anspruch auf Beseitigung der auf ihrem Grundstück verbliebenen Teile des Werkstattanbaus aus § 1004 I 1 haben.

I. Eigentum der N am Nachbargrundstück

N müsste Eigentümerin des beeinträchtigten Grundstücks sein; dies ist hinsichtlich des Nachbargrundstücks der Fall.

II. Eigentumsbeeinträchtigung durch die Gebäudereste

Ferner müsste das Eigentum der N beeinträchtigt sein. Eine Eigentumsbeeinträchtigung i.S.d. § 1004 I ist jeder dem Inhalt des Eigentums widersprechende Zustand, der nicht in einer Entziehung oder Vorenthal-

---

114 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …]

115 [Quelle einfügen]

tung des Besitzes besteht;[116] die Einwirkung darf nach Dauer und Intensität nicht völlig unerheblich sein.[117] Die Reste des Werkstattanbaus nehmen dauerhaft Fläche des Grundstücks der N in Anspruch und schränken ihre Nutzungsmöglichkeit ein. Eine Beeinträchtigung liegt damit grundsätzlich vor. Fraglich ist jedoch, ob N diesen Zustand aufgrund der Vorschriften über den Überbau dulden muss.

1. Ursprüngliche Duldungspflicht nach § 912 I BGB

N könnte zunächst gem. § 912 I zur Duldung verpflichtet gewesen sein. Danach muss der Nachbar einen Überbau dulden, wenn der Eigentümer bei der Errichtung eines Gebäudes ohne Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit über die Grenze gebaut und der Nachbar nicht vor oder sofort nach der Grenzüberschreitung widersprochen hat.

a) Überbau bei Errichtung eines Gebäudes

Zunächst müsste ein Überbau vorliegen. Ein solcher ist gegeben, wenn ein einheitliches Gebäude, das vom Stammgrundstück aus errichtet wird, die Grenze überschreitet und teilweise auf dem Nachbargrundstück steht.[118] Der Vater der V errichtete als damaliger Eigentümer des Stammgrundstücks den Werkstattanbau, der teilweise auf dem Grundstück der N steht. Damit ist ein Überbau gegeben.

b) Weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit des Überbauenden

Dem Vater der V dürfte hinsichtlich der Grenzüberschreitung weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen.[119] Da ihm der Grenzverlauf unbekannt war, handelte er nicht vorsätzlich. Grob fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt und schon naheliegende Überlegungen nicht anstellt.[120] Der Vater der V hatte die verfügbaren Unterlagen sorgfältig geprüft; gleichwohl war die Grenzüberschreitung für ihn nicht erkennbar. Ihm fällt folglich keines von beidem zur Last.

c) Kein sofortiger Widerspruch der N

N dürfte nicht vor oder sofort nach der Grenzüberschreitung widerspro chen haben.[121] Sie beobachtete die Errichtung des Anbaus und erkannte

116 [Quelle einfügen]
117 [Quelle einfügen]
118 [Quelle einfügen]
119 [Quelle einfügen]
120 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …]
121 [Quelle einfügen]

bereits währenddessen, dass Teile auf ihrem Grundstück entstanden. Gleichwohl widersprach sie erst zwei Monate nach der Fertigstellung. Ihr Widerspruch war damit nicht rechtzeitig.

d) Zwischenergebnis zu § 912 I BGB

Die Voraussetzungen des § 912 I lagen bei Errichtung des Werkstattanbaus vor.

e) Rechtsfolgen des entschuldigten Überbaus

N war daher zur Duldung des Überbaus verpflichtet und ist hierfür gem. § 912 II 1 durch eine Geldrente zu entschädigen.[122] Zugleich bleibt der hinübergebaute Gebäudeteil sachenrechtlich dem Stammgrundstück zugeordnet und steht im Eigentum des jeweiligen Eigentümers des Stammgrundstücks.[123]

2. Fortwirkung gegenüber den Rechtsnachfolgern V und K

Die Duldungspflicht müsste auch gegenüber K fortgewirkt haben. Als dingliche Beschränkung des Eigentums besteht sie gegenüber dem jeweiligen Eigentümer des Stammgrundstücks.[124] Dieses ging gem. § 1922 I auf V als Alleinerbin und sodann auf K über, die damit in die Rechtsstellung aus § 912 I einrückte.

3. Erlöschen der Duldungspflicht durch den Teilabriss

Die Duldungspflicht könnte jedoch durch den Teilabriss erloschen sein. § 912 soll verhindern, dass wirtschaftliche Werte durch die Zerschlagung eines einheitlichen Gebäudes vernichtet werden; geschützt ist also der Bestand des grenzüberschreitenden Gebäudes als wirtschaftliche Einheit.[125] K ließ den auf ihrem Grundstück befindlichen Teil des Werkstattanbaus abreißen und hat diese Einheit damit selbst aufgehoben.[126] Die auf dem Grundstück der N verbliebenen Reste bilden kein Gebäude mehr, dessen Erhalt § 912 sichern könnte. Mit dem Schutzzweck der Norm ist auch die Duldungspflicht der N entfallen.

4. Eigentumslage an den Gebäuderesten

Fraglich ist weiter, wem die Gebäudereste gehören. K meint, sie gehörten nun der N. Zwar sind fest mit dem Grund und Boden verbundene

122 [Quelle einfügen]
123 [Quelle einfügen]
124 [Quelle einfügen]
125 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …]
126 [Quelle einfügen]

Gebäude gem. § 94 I grundsätzlich wesentliche Bestandteile des Grund stücks, auf dem sie stehen.[127] Beim Überbau gilt aufgrund der §§ 912 ff. jedoch eine abweichende Zuordnung zum Stammgrundstück.[128] Der Abriss des auf dem Stammgrundstück stehenden Teils ändert an dieser Zuordnung nichts, sodass die Reste nicht nachträglich Bestandteil des Grundstücks der N werden.[129] Die Auffassung der K trifft daher nicht zu; sie ist Eigentümerin der Gebäudereste geblieben.

III. Verantwortlichkeit der K als Störerin

K müsste Störerin sein. Handlungsstörer ist, wer die Beeinträchtigung durch sein Verhalten adäquat verursacht hat;[130] als Zustandsstörer haftet dagegen, wer sie nicht selbst herbeigeführt hat, aber durch seinen maßgebenden Willen aufrechterhält.[131] Voraussetzung ist, dass er die Störung beseitigen kann und sie ihm zurechenbar ist.[132] Zwar hat nicht K, sondern der Vater der V den Anbau errichtet. K ist jedoch Eigentümerin der Gebäudereste und kann diese beseitigen. Zudem hat sie durch den Teilabriss selbst bewirkt, dass aus dem zu duldenden Überbau eine nicht mehr zu duldende Beeinträchtigung wurde, und lässt die Reste bewusst stehen. Die Beeinträchtigung ist ihr daher zurechenbar; K ist jedenfalls Zustandsstörerin.

IV. Kein Ausschluss nach § 1004 II BGB

Schließlich dürfte N nicht zur Duldung verpflichtet sein, § 1004 II. Die Pflicht aus § 912 I ist aber entfallen; andere Gründe fehlen.

V. Ergebnis zu Frage 4

N kann von K gem. § 1004 I 1 die Beseitigung der Reste verlangen.

---

127 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …; Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …]
128 [Quelle einfügen]
129 [Quelle einfügen: Bearbeiter, in: Werk, § … Rn. …; BGH, Urt. v. … – Az. …, Fundstelle …]
130 [Quelle einfügen]
131 [Quelle einfügen]
132 [Quelle einfügen]